

1502568-24.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... apreendidos indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502568-24.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502568-24.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO BUENO FERREIRA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

ROGÉRIO BUENO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, caput, do Código Penal, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, cinco porções de haxixe, maconha separadas em dois sacos plásticos contendo 29 e 31 porções, uma porção de maconha em tubo plástico, 34 pedras de crack e 76 porções de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica. Foi também apreendida em posse do acusado a quantia de R\$55,00.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o réu opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-lo.

O réu foi notificado e ofereceu defesa preliminar. Recebida a denúncia, o acusado foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao

final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos ao apenamento e ao regime prisional.

A Defesa, por sua vez, suscitou a preliminar de inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, por falta de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena e fixação do regime prisional.

É o relatório.

DECIDO.

Rejeito a preliminar de inépcia da denúncia arguida pela Defesa.

A inicial é perfeita, inexistindo mácula a ser reconhecida.

A denúncia descreve os fatos relativos ao réu, possibilitando, assim, o irrestrito exercício da ampla defesa.

Como cediço, somente quando se trate de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração dos fatos principais é que a denúncia pode ser considerada inepta, caso não possa ser suprida por outros elementos de prova, antes da sentença final, o que não ocorre nos autos.

No mérito, a ação penal procede .

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, pelas fotografias de fls. 16 e 39/52, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime. Disse que havia comprado maconha pela quantia de R\$10,00 de um indivíduo que estava em um beco e usava boné vermelho e, após, foi ao comércio de Junior para tomar café da manhã. Alegou que, subitamente, dois homens desembarcaram de um veículo de cor preta, sem identificação, e disseram ser policiais civis, embora não trajassem vestimenta da Polícia Civil. Disse que ficou nervoso, pois estava com fome e porque não conhecia aqueles dois homens, razão pela qual começou a gritar. Alegou que foi golpeado por um dos policiais e foi, então, algemado pelos pés e pelas mãos, sendo conduzido à delegacia, onde, submetido à busca pessoal, foram encontradas as duas porções de maconha que havia adquirido. Contou que os policiais apresentaram, na delegacia, uma sacola, que não era de sua propriedade. Disse que não viu nada sendo encontrado nas proximidades do local da abordagem. Alegou que, quando abordado, debateu-se por ter imaginado que iriam matá-lo e negou ter agredido os policiais. Declarou que não conhecia os policiais que o abordaram na data dos fatos e contou que a policial feminina não participou da abordagem, havendo somente dois policiais masculinos no local dos fatos. Alegou ser somente usuário de entorpecentes. Disse que Junior e a dona do bar ao lado de seu comércio viram os fatos, pois gritou para que chamassem sua família, tendo sido esse o momento em que foi algemado, colocado na viatura e conduzido à delegacia. Disse que foi detido em frente ao bar de Junior.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha policial civil Daniel Maia Silveira, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, recebida notícia acerca de um indivíduo que estaria realizando o tráfico de drogas, com indicação do local, próximo a uma unidade de saúde e quase em frente a um bar, deslocou-se ao ponto indicado juntamente com sua parceira de equipe, em viatura descaracterizada, a fim de averiguar a informação. Narrou que, durante a campana, viu, por duas vezes, que pessoas aproximavam-se do réu, entregavam algo a ele, e viu que o réu atravessava a rua, dirigindo-se até uma moita, de onde ele retirava algo que, em seguida, entregava a quem o aguardava, que ia embora do local. Declarou que, em razão da movimentação típica de tráfico de drogas que pode presenciar, realizou a abordagem do acusado. Disse que, feita a busca pessoal, no bolso direito da bermuda do réu foram encontradas duas porções de maconha, além de cerca de R\$55,00 em dinheiro. Realizada a busca no lado oposto da rua, na moita onde viu o acusado buscar objetos, foram localizadas porções de

maconha, crack e cocaína, em quantidade que não se recordava. Relatou que, dada a voz de prisão, o réu tentou agredir a equipe policial e foi necessário contê-lo com o uso moderado de força. Narrou que o acusado não forneceu esclarecimentos quanto às drogas e dinheiro apreendidos quando estavam no local dos fatos, porém, na delegacia, informalmente, disse que estava desempregado e admitiu ter praticado o delito a fim de sustentar sua família. Disse que não conhecia o réu anteriormente aos fatos. Consignou que o local dos fatos tratava-se de uma comunidade e procurou ser rápido quando da abordagem para não exaltar os ânimos de populares. Disse que havia pessoas próximas ao local dos fatos, mas ninguém apresentou-se como testemunha. Declarou que, após a abordagem, recebeu a notícia, por um informante que não presenciou a abordagem do réu, de que indivíduos armados estariam rumando em direção ao local dos fatos para tentar resgatar o acusado da equipe policial. Narrou que a notícia anônima foi recebida diretamente no telefone do plantão policial da delegacia e indicava características do indivíduo que estaria traficando, sendo informado que a pessoa seria magra, de cor parda, de estatura mediana e que trajava bermuda e agasalho. Asseverou que, ao ver o acusado no local indicado na notícia recebida, constatou que suas características coincidiam com aquelas informadas, fator este que permitiu sua identificação para a realização da campana. Declarou que os fatos ocorreram no período da manhã e esclareceu que a prisão do acusado ocorreu em frente ao arbusto, mas do lado oposto da rua, pois ele somente dirigia-se àquele local para buscar a droga e entregá-la ao comprador. Relatou que a campana foi realizada a uma distância de aproximadamente 50 metros do local em que o réu estava, pois a viatura foi estacionada em uma rua a 90 graus do local dos fatos. Declarou que o acusado reagiu de forma violenta e foi rapidamente retirado do local dos fatos. Afirmou que somente participou da abordagem a policial feminina e não havia outro policial masculino. Esclareceu que, ao colocar a algema em um dos braços do acusado, ele investiu contra a policial feminina e foi necessário imobilizá-lo, a fim de algemá-lo. Disse que o réu tentou agredir a policial feminina, possivelmente para tentar fugir.

No mesmo sentido, a testemunha policial civil Ana Paula Soares Lopes, ouvida em Juízo, narrou que, em razão de informação recebida por chamada no telefone da delegacia, foi com seu parceiro ao local dos fatos e, a uma distância de aproximadamente 50 metros, realizaram campana por cerca de uma hora. Afirmou que viu uma pessoa aproximar-se do acusado, entregar algo em sua mão e, na sequência, viu o réu atravessar a rua até uma moita ou arbusto, de onde retirou algo que entregou ao indivíduo que o aguardava. Relatou que, então, mais um rapaz que estava de bicicleta aproximou-se do réu e a mesma ação se repetiu. Declarou que, realizada a abordagem do réu e a busca pessoal, em seu bolso direito foram encontradas duas porções de maconha e, no bolso esquerdo, uma quantia em dinheiro, cujo valor não se recordou. Narrou que o acusado avançou em sua direção e foi, então, contido. Relatou que, na moita, foi localizada uma sacola contendo maconha, crack e cocaína, em quantidade que não se recordou. Declarou que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos e não recordou se ele forneceu explicação para as drogas encontradas. Disse que o acusado estava sozinho no local em que a prisão ocorreu. Não recordou o horário em que se deram os fatos, nem lembrou-se em que rua eles ocorreram, porém narrou tratar-se de local movimentado. Disse que a prisão não foi realizada em frente a um bar. Relatou que a diligência foi realizada em viatura descaracterizada, de cor escura. Narrou que não foi realizada a abordagem dos indivíduos que se aproximaram do acusado. Disse que o réu trajava bermuda, possivelmente de cor verde e um casaco, possivelmente de cor preta. Consignou que o acusado incitou a população contra a equipe policial.

A testemunha de defesa Dore Edson Godoy Vecchi disse ter presenciado a abordagem do acusado. Contou que estava levando três caixas de coca-cola para João, dono de um comércio com quem realiza compra conjunta dos refrigerantes e, no momento em que chegava com as caixas, viu os policiais abordando o réu. Declarou que tais fatos ocorreram nas proximidades da mercearia de João, entre este comércio e um bar ao lado. Disse que, após a abordagem, foi embora do local e nada mais viu. Relatou não recordar se havia outras pessoas próximas à abordagem, mas consignou que João estava no local consigo para receber as caixas que levava para ele e,

possivelmente, presenciou o ocorrido. Contou que não conhecia o réu anteriormente aos fatos e disse que foi procurado por parentes dele para servir como testemunha. Disse que nenhum parente do acusado estava no local no momento da abordagem, porém familiares do réu procuraram Junior e depois o procuraram. Contou que a abordagem foi realizada por dois policiais masculinos.

A testemunha de defesa João Vieira da Silva Junior disse que presenciou a abordagem do acusado, que ocorreu por volta de 10 a 11 horas, entre sua mercearia e o bar vizinho. Declarou que a abordagem foi presenciada também por Dore, que foi ao local para pegar refrigerante consigo, pois realizam compra conjunta e a dividem. Contou que a abordagem ocorreu no momento em que Dore foi pegar as caixas de coca-cola consigo. Disse não ter visto se os policiais localizaram algo com o réu e declarou ter presenciado os fatos até o momento em que o acusado foi conduzido à delegacia, mas Dore não permaneceu no local. Contou ter visto o momento em que policiais trouxeram algo na mão e atribuíram a propriedade do objeto ao réu. Disse que serve café da manhã em seu comércio e o acusado, algumas vezes, ia ao local para tomar o café. Declarou que o réu havia pedido o café da manhã e, então, foi prepará-lo, sendo que, no momento em que iria entregar o pedido ao acusado, viu a abordagem. Disse que, em razão do período de pandemia, não permitia que ninguém entrasse no comércio e, por essa razão, o réu ficou aguardando ao lado de fora. Contou que a abordagem foi realizada por dois policiais masculinos, que estavam em um veículo de cor preta. Declarou que, em dado momento, o réu revoltou-se e discutiu em tom de voz alto, negando a prática do crime, o que fez com que populares se insurgissem contra os policiais. Disse que a rua onde ocorreram os fatos é movimentada.

Questionado pelo Ministério Público se havia participado como testemunha em processos relativos a fatos e indivíduos diversos e se conhecia as pessoas de nome Gledson Santos Souza, Rafael Conceição dos Santos, Diego Henrique Bueno da Conceição e Rodrigo Martins dos Santos, disse conhecer Rafael, pois este trabalhou consigo anteriormente, e Diego, pois seria seu sobrinho, embora não tivesse certeza de tratar-se da mesma pessoa. Declarou que não prestou depoimento como testemunha no processo em face de Diego e, quanto a Rafael, havia apenas apresentado carta de referência de que aquele trabalhava consigo.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminoso do acusado quanto ao crimes de tráfico de drogas e de resistência a ele imputados, diante das provas produzidas. Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga com ele, bem como no local onde ele as mantinha em depósito.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu “é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se “imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento” (TJSP – AP – Rel. Walter Guilherme – j. 10.03.98 – JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se

favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2^a T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1^a Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).
4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.
5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.
6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.
7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por

gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos dos policiais civis, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e a localização dos entorpecentes, e, ao contrário do alegado pela Defesa, encontram-se em verdadeira harmonia com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Veja-se que as testemunhas policiais, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, afirmaram que puderam presenciar o acusado realizar o ato de mercancia ilícita de drogas para dois indivíduos, esclarecendo que presenciaram indivíduos aproximando-se do réu, entregando algo a ele, bem como viram o réu dirigir-se a um arbusto, de onde pegava algo que, em seguida, entregava a quem o estava aguardando.

Em Juízo, as testemunhas policiais civis apenas puderam fornecer informações mais detalhadas acerca da dinâmica em que ocorreram os fatos, esclarecendo que a diligência policial realizou-se em razão de notícia recebida, por telefone, na delegacia, além de relatarem pormenorizadamente a conduta do acusado e a abordagem realizada.

A testemunha Daniel pode acrescentar que a informação recebida em solo policial já indicava as características físicas e de vestimenta do indivíduo que estaria realizando o tráfico de drogas e consignou que todas as características do réu eram compatíveis com a notícia dada, o que possibilitou sua identificação para a realização da campana.

Asseveraram as testemunhas policiais que viram o ato de traficância realizado pelo réu por duas vezes e, após a abordagem, localizaram as drogas em posse do acusado e também em uma moita ao lado oposto da rua, local onde o viram mexer.

Outrossim, ambas as testemunhas afirmaram que o acusado avançou na direção da policial Ana Paula, tendo esclarecido o policial Daniel que o réu tentou agredir sua parceira, investindo contra ela, tendo sido necessário o uso moderado de força para algemá-lo.

Finalmente, a alegação da Defesa de que não havia rua perpendicular e, portanto, a 90 graus, da rua em que ocorreram os fatos não corresponde à imagem anexada em seu memoriais, às fls. 342, de onde se depreende haver uma rua à direita do ponto marcado que, visualmente, encontra-se a uma curta distância do local em que o réu foi avistado.

Não há dúvidas, portanto, que o acusado estava portando drogas e também que eram de sua propriedade as drogas em depósito apreendidas no local onde o réu havia mexido momentos antes da abordagem, quando efetivamente praticou o ato de comércio de entorpecentes.

De outro lado, as declarações das testemunhas arroladas pela Defesa não abalaram em nada os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Ressalte-se que a testemunha Dore disse somente ter presenciado a abordagem do réu, sem nada mais observar, pois foi embora do local em seguida.

Já a testemunha João claramente tentou beneficiar o acusado. Disse ter presenciado a abordagem, porque esta ocorreu no momento em que Dore estava pegando caixas de refrigerante em seu comércio.

Disse então, a testemunha João, que o réu estava ao lado de fora de sua mercearia, aguardando o pedido de café da manhã que ele havia feito anteriormente e que, no momento em que saiu para fazer a entrega ao réu, viu que ele estava sendo abordado. Note-se que João disse não ter visto se os policiais encontraram algo com o acusado, porém disse ter visto os policiais com algo em suas mãos, cuja propriedade foi atribuída àquele, versão esta que sequer coincide com aquela apresentada pelo réu, que alegou terem os policiais apresentado uma sacola somente na delegacia. Outrossim, verifica-se dos documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público (fls. 282/301), que a testemunha João, ao contrário do que afirmado por ela em Juízo, forneceu declarações como testemunha em processos relacionados a fatos e indivíduos diversos.

As incongruências apresentadas no depoimento de João, não somente quanto a ter servido como testemunha em outros feitos, mas também quanto à dinâmica do que o levou à porta de seu estabelecimento no momento em que ocorreu a abordagem, infirmam o valor probante de suas declarações.

Assim, nada há nos autos a infirmar a palavra das testemunhas policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado.

Finalmente, a falta de outras testemunhas civis que tenham presenciado a abordagem não retira a validade e força probante das declarações prestadas pelas testemunhas policiais.

Verifica-se, inicialmente, que as testemunhas policiais relataram hostilidade da população local contra a equipe policial.

De outro lado, ressalta-se que é amplamente sabido que testemunhas civis sobre crimes ligados ao tráfico de drogas são muito difíceis de serem levadas perante a Autoridade Policial, pois o medo que impregna a população acerca do mencionado crime é reflexo da estruturação advinda dele, alimentada pelos vultosos lucros conseguidos e pelo chamado “código de ética”, pregado, na maioria das vezes, nos locais mais humildes, o qual, se desobedecido, os colaboradores pagam com a própria vida.

Dessa forma, a versão apresentada pelo acusado, além de não se mostrar crível, restou absolutamente isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se ao depoimento dos policiais encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem os delitos.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos, bem como as diligências realizadas no curso da ação penal, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Consigne-se que não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas. Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do acusado deriva da grande quantidade e da variedade, bem como das demais circunstâncias em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos. De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos

variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310). Provadas, portanto, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu em relação a esse delito é medida que se impõe.

Da mesma forma, o crime de resistência restou bem configurado. Conforme já exposto, as testemunhas policiais asseveraram que o acusado opôs-se à execução do ato legal, mediante violência.

Afirmaram os policiais Daniel e Ana Paula que o réu, no momento da abordagem, efetivamente investiu contra a policial Ana Paula, tentando agredi-la. Consignaram as testemunhas que foi necessário o uso de força moderada para a contenção do acusado.

Veja-se que, embora a testemunha Daniel tenha declarado que o acusado possivelmente agiu desta forma para conseguir fugir, afirmou a testemunha que, inclusive, já havia algemado um braço do réu quando ele investiu contra sua colega, o que demonstra sua intenção de opor-se à execução do ato legal dos policiais, mediante violência.

Verifica-se que a conduta do réu, que antecedeu à abordagem policial, bem como a constatação de que ele trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de entorpecentes variados, justificou o ato dos policiais que, por isso, mostrou-se legal.

Assim, diante da prova produzida, conclui-se com tranquilidade a subsunção dos fatos narrados ao artigo 329, caput, do Código Penal.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas:

Diante da natureza e da variedade de drogas apreendidas na posse do acusado, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mas sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se, portanto, o aumento da pena. Outrossim, o acusado é portador de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 55 e 57/58. Assim, aumento a pena-base do acusado em 1/3, ficando ela fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, verifico que o réu é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 55/56, motivo pelo qual aumento sua pena em 1/6, a qual resta fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor já estabelecido.

Consigno que não haveria que se falar em bis in idem no aumento de pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena em razão de existência de duas condenações criminais transitadas em julgado. Esse é o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confirmado em decisão recente:

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.

DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE.

ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS QUE NÃO SE AFIGURAM INERENTES AO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA JUSTEZA DA

REPRIMENDA NO ÂMBITO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE

HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com

acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e

fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do

crime. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o

magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa

regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da

República. 2. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há

ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no

reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O

que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em

momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes. 3. O aumento da pena-base acima do mínimo legal, quanto ao crime de resistência, restou suficientemente fundamentado, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. Isso porque, conforme consignou o Juízo sentenciante, o Acusado, no momento de sua prisão, ofendeu a integridade física de policial militar e incitou populares e familiares a agredi-lo, instigando-os, inclusive, a subtrair a arma do miliciano. 4. Não havendo ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, essa via não é adequada para dizer se foi justa ou não a reprimenda aplicada ao Paciente. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus denegada." (STJ – HC 213240/SP 2011/0163921-1. Rel Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. Data do Julgamento 05/09/2013 DJE 11/09/2013).

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, a qual resta fixada em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência do acusado, bem como diante grande quantidade da droga apreendida.

Com efeito, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa. Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II Não procede a alegação de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes. III Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV Não caracteriza bis in idem a consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu

seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. VI Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de diminuição. VII – Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).

Ainda no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. "1. Constatando-se que a paciente ostenta maus antecedentes, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra. "2. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante da agente, somadas à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder - mais de 3 quilos de maconha -, ademais, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa..." (STJ HC 230.835/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012).

Outrossim, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritivas de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS , Quinta Turma, julgado em 16/03/2017 , PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Ademais, a grande quantidade, além da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos indicam que o réu faz do tráfico de drogas seu meio de vida, ou seja, dedica-se à atividade criminosa, não podendo ser considerado como pequeno traficante, conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM PROPORCIONAL À NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria

penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, ante a natureza bastante lesiva da substância ilícita (crack), em consonância com o atual entendimento do col. Pretório Excelso, bem como desta eg. Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 630.134/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Considerando as peculiaridades do presente caso e as condições previstas no artigo 59 do Código Penal, cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, notando-se seu aspecto altamente nocivo à sociedade que em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, considerando-se, ainda, os maus antecedentes e a reincidência do acusado, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena.

Não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

2. Quanto ao crime de resistência:

Quanto ao crime de resistência, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico ser o réu portador de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 55 e 57/58, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, ficando ela fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o acusado é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 55/56, devendo a pena ser aumentada em 1/6 fixando-a em 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Ainda, o crime foi praticado em ocasião de calamidade pública, nos termos já expostos. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, a qual resta fixada em 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Torno esta pena definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras.

Fixo o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante da reincidência do réu, bem como das circunstâncias judiciais que lhe são negativas.

Pelas mesmas razões, não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa por liberdade por restritiva de direitos. Também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados